

1501958-71.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501958-71.2020.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501958-71.2020.8.26.0510 - 2020/000430

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO BELTRAN RUIZ

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LUIS ANTONIO BELTRAN RUIZ, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 14 de julho de 2020, por volta das 17:00 horas, na Avenida 11, com a Rua 21, Jardim Claret, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 07 (sete) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol, totalizando peso líquido aproximado de 12,0 gramas, 43 (quarenta e três) microtubos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 7,6 gramas, bem como 04 (quatro) invólucros contendo a mesma substância entorpecente, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 28,5 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 15/18, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 22 de outubro de 2020.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto.

Já a ilustre Defensora Pública inicialmente sustentou comprometida a materialidade do delito em função da ilícita busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente, desacompanhada de fundada suspeita sobre a ocorrência do delito, em violação ao disposto no artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição nos termos do artigo 386, inciso II, do mesmo Estatuto Processual Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, buscou-se a desclassificação do delito irrogado ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, assim porque também não evidenciada a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão inicialmente externada, como também posteriormente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, operando-se a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, transportava o entorpecente descrito na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 88/90, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida em função de ilícita busca pessoal realizada, em afronta ao disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Entretanto, afirmaram os Policiais Militares que na ocasião estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado conduzindo uma bicicleta, já conhecido nos meios policiais de localidade denominada de "beco", onde ocorre intensa comercialização de entorpecente, tendo ele demonstrado nervosismo com a aproximação da guarnição, por isto que acabou sendo abordado, estas circunstâncias, associadas ao tirocínio policial, constituindo, portanto, a fundada suspeita autorizadora da medida invasiva, tanto que resultou efetivamente na apreensão de porções de cocaína, crack e maconha, acondicionadas em uma embalagem que estava sendo transportada pelo acusado.

Deste modo, respeitada a objeção deduzida, diante dos elementos concretamente considerados, não se entende ilícita a busca pessoal realizada, a comprometer, por derivação, a materialidade do delito.

Controverte-se sobre a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Inicialmente ouvido, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu a prática do delito que lhe está sendo irrogado, assim se manifestando: "os caras do Bairro do Estádio me mandaram ir no bairro Bom Sucesso para pegar um saquinho com droga, que estava "em um mocó". Eu fui e peguei. Por fazer isso, eu iria ganhar 03 pedras de crack..." (fls. 6).

Em juízo deduziu outra versão, desta feita admitindo tão somente o transporte da embalagem apreendida em seu poder, mas observando que não tinha conhecimento de que se tratava de entorpecente.

Todavia, tem-se afirmado que a confissão vale menos pelo lugar em que externada, do que pelo conteúdo de veracidade que encerra, à luz do conjunto probatório.

De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, reiterando o que inicialmente exposto, afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado, já conhecido de uma localidade onde se realiza intenso tráfico de entorpecente, conduzindo uma bicicleta, demonstrando nervosismo quando dele se aproximaram, por isto que seguiu-se uma abordagem, apreendendo-se com ele uma sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha, admitindo então o acusado estava transportando o entorpecente, a pedido de terceiro, não identificado.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, as circunstâncias que determinaram a abordagem do acusado, transportando uma sacola com várias porções de cocaína, crack e maconha, a pedido de terceiro que sequer conhecia, associadas à confissão inicialmente externada, permitem conclusão segura sobre a prática do delito que lhe é atribuído, bem assim sobre a destinação mercantil do entorpecente apreendido, composto de várias porções já individualizadas de naturezas diversas.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Presentes os requisitos autorizadores, sendo o acusado primário, não havendo demonstração de que integre organização criminoso ou que esteja efetivamente dedicado ao comércio ilícito, deve a pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, de tal modo que, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente

cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado LUIS ANTONIO BELTRAN RUIZ à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA